

1501817-06.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501817-06.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501817-06.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2199399/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 26301323 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO NASCIMENTO FERREIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

DIEGO NASCIMENTO FERREIRA, MARCOS ROBERTO DA SILVA e GUSTAVO SANTOS FERNANDES DE PAULA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por duas vezes, no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 22 de julho 2022, por volta das 20h00min, na Avenida Silvestre Pires de Freitas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, DIEGO NASCIMENTO FERREIRA, MARCOS ROBERTO DA SILVA e GUSTAVO SANTOS FERNANDES DE PAULA, em concurso de pessoas, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo e chave falsa, o veículo FIAT/Uno, placas BSU-4623, vermelho, avaliado em R\$ 8.420,00 (Auto de fls. 16), pertencente à vítima Reinaldo Aparecido da Silva. Consta também que, no dia 22 de julho 2022, por volta das 23h40min, na Rua Eugênio Diamante, 517, nesta cidade e comarca de Guarulhos, DIEGO NASCIMENTO FERREIRA,

MARCOS ROBERTO DA SILVA e GUSTAVO SANTOS FERNANDES DE PAULA, em concurso de pessoas, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo e chave falsa, uma bateria automotiva, avaliada em R\$ 380,00 (Auto de fls. 16), que estava acoplada ao veículo FIAT/Uno, placas KND-9637, branco, pertencente à vítima Lady Mariana Pereira Gomes (fls. 128/130).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/123).

A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2022 (fls.131/132).

Os acusados foram citados (réu Diego - fls. 149/150, réu Gustavo - fls. 151/152 e réu Marcos - fls. 147/148) e apresentaram resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 156/158).

Em 27 de setembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 168/171).

Nesta data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de quatro testemunhas comuns. Em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Pelo Ministério Público foi oferecido acordo de não persecução ao corréu Gustavo, que foi aceito e homologado, prosseguindo-se a ação apenas com relação aos corréus Marcos e Diego.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/12), auto de exibição/apreensão e avaliação (fls. 16/17 e fls. 20/21), auto de reconhecimento de objeto (fl. 19), autos de entrega (fl. 20 e fl. 21), laudo pericial de exame de peça (fls. 256/258), laudo pericial veicular (fls. 259/263), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria delitiva é segura e aponta para os acusados, senão vejamos.

Os acusados DIEGO NASCIMENTO FERREIRA, MARCOS ROBERTO DA SILVA e GUSTAVO SANTOS FERNANDES DE PAULA, em solo policial, exerceram o direito de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas em juízo (fl. 06, fl. 07 e fl. 08).

Em juízo, os acusados confessaram os crimes. Todos disseram terem furtado o veículo fiat vermelho usando o pedaço de tesoura como chave mixa. Admitiram também terem furtado a bateria após quebrar a grade para destravar o capô do veículo.

A confissão dos acusados foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima LADY MARIANA PEREIRA GOMES, em solo policial, disse que é dona do carro de placa KND9637, o qual estacionou na frente da sua casa, na Rua Eugenio Diamante, 517, ontem por volta das 17h. Por volta das 23h40min, sua vizinha ligou dizendo que 3 homens estavam furtando seu carro e que eles estavam em um Fiat Uno vermelho. Ao testemunhar o furto, ela saiu na varanda e gritou, impedindo que os 3 furtadores levassem seu carro, porém eles conseguiram subtrair a bateria. Não viu arrombamento em seu carro. Neste ato, reconhece a bateria apresentada neste DP como sendo sua.

Assim, recebe a mesma (fl. 04). Em juízo, disse que foi roubada a bateria de seu carro. A vizinha lhe avisou do furto, praticado por três pessoas, mas, quando chegou, os agentes já tinham entrado no carro usado no crime, um Uno vermelho. Constatou, então, que o seu carro estava aberto e a bateria estava faltando. O crime ocorreu por volta das 23h40 e meia noite. Logo depois, policiais lhe contataram, dizendo os agentes foram detidos no interior de um carro furtado, assim como com uma bateria furtada, que a depoente reconheceu como sendo sua. Reconheceu, igualmente, o carro no qual os réus foram encontrados, onde estava a bateria furtada..

A vítima REINALDO APARECIDO DA SILVA, em solo policial, disse que ontem estava na posse do carro de seu pai, cuja placa é BSU4623, o qual deixou estacionado na Av Silvestre Pires de Freitas por volta das 19h, pois foi em um culto. Quando retornou, por volta das 21h, constatou que ele havia sido furtado. Não teve tempo

de fazer BO, nem ligou para 190, pois foi pessoalmente na base da PM que fica na Praça Oito, onde contou sobre o furto. Por volta da 1h estava em casa quando recebeu uma ligação da PM avisando que seu carro tinha sido achado. Veio para este e esclarece que aparentemente o carro não teve danos (fl. 05). Em juízo, disse que estacionou seu carro na rua e, ao voltar, percebeu que ele foi furtado. Fez a notícia do furto na polícia e, certo tempo depois, foi contatado pela polícia sobre o encontro do carro. Foi ao DP, onde recebeu seu carro. O aparelho de som, todavia, estava faltando. AS fechaduras não estavam arrombadas, então acredita que usaram uma mixa.

Mas não é só.

O policial militar LUCAS JOSÉ DA SILVA, em solo policial, disse que ontem (22/07/22), por volta das 19h, o COPOM irradiou que um veículo Fiat Uno vermelho tinha sido furtado. Diligenciou pela região e, por volta da 0h, na Rua Ana Coelho da Silveira, 196, logrou localizar o Fiat Uno vermelho de placa BSU4623. Dada ordem de parada, os 3 ocupantes obedeceram. Marcos Roberto da Silva era motorista, Diego Nascimento Ferreira era passageiro dianteiro e Gustavo Fernandes de Paula era passageiro traseiro. Dentro do carro, no assoalho do passageiro dianteiro, havia uma bateria automotiva, enquanto na ignição havia uma metade de tesoura funcionando como chave micha. Indagados, os 3 confessaram o furto do Fiat Uno vermelho e da bateria, explicando que esta última eles furtaram de um Fiat Uno branco que estava estacionado próximo do supermercado Barbosa da Av. Otavio Braga de Mesquita. Diante dos fatos, solicitaram apoio e outra guarnição logrou encontrar o veículo Fiat Uno branco de placa KND9637 estacionado na Rua Eugenio Diamante, 507, que é uma paralela da Av. Otavio Braga de Mesquita. O Fiat Uno branco está arrombado, tanto na porta do motorista quanto no capô. Acredita que eles iriam levar o próprio carro, mas como ele tem uma trava, os furtadores levaram só a bateria. A vítima Leide Mariana Pereira Gomes foi contatada e reconheceu a bateria como sendo dela, furtada do Fiat Uno branco. A vítima Reinaldo Aparecido da Silva também foi contatada, pois ele é dono do Fiat Uno vermelho furtado. Ambas vieram para este DP. Diante dos fatos, proferiu voz de prisão e conduziu todos os furtadores para este DP (fl.02). Em juízo, disse que receberam a notícia do furto do veículo FIAT/Uno, placas BSU-4623, vermelho. Em policiamento, encontraram os réus no carro. Em tal carro, foi encontrada uma tesoura que, segundo o réu Marcos foi usada como chave falsa para abrir e acionar o veículo. No carro ainda havia uma bateria, que foi indicada por Marcos como sendo produto de outro furto, tendo sido informado o local onde estava o carro saqueado. Foram ao local, onde localizaram o Fiat branco, que estava com a grade da frente arrombada e com a bateria retirada. Marcos confessou o crime, e imputou o crime as demais réus que, por sua vez, negaram o delito. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Pois bem, diante da confissão do acusados, acrescida das declarações das vítimas, depoimentos da testemunha policial, em ambas as fases da persecução penal, bem como do fato dos acusados terem sido apreendidos no interior do veículo furtado e em poder da bateria subtraída, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a autoria dos delitos de furto que lhes estão sendo imputadas, afastando a alegação de insuficiência probatória.

Além da certeza da participação do acusado nos dois crimes de furto, com igual precisão restou evidente a qualificadora do concurso de agentes para ambos os delitos, diante da forma de atuação dos acusados, agindo em conjunto entre si, todos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer um deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar as práticas criminosas.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: “Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível” (RJDTACRIM 23/96).

Quanto ao delito do furto da bateria, inquestionável também a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, diante das declarações da vítima e da testemunha policial, bem como da própria confissão do acusado, que confirmarem que o veículo foi arrombado, ou seja, teve a grade rompida para que os réus abrissem o capô.

Ademais, o laudo pericial de fls. 259/263 através da fotografia de fls. 262 atesta tal rompimento.

Já quanto a qualificadora do uso de chave falsa, esta deve ser afastada, uma vez que não há provas de que o objeto apreendido (pedaço de tesouro) chegou a ser usado para subtração da bateria.

Por outro lado, quanto ao delito de furto do veículo Fiat Uno vermelho, presente a qualificadora do uso de chave falsa, conforme admitido pelos acusados, objeto este que foi apreendido pelos policiais, conforme auto de exibição/ apreensão e avaliação (fls. 16/17) e devidamente periciado pelo laudo de exame de peça de fls. 256/258.

Já no que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, não há evidências de que os acusados teriam rompido qualquer obstáculo para o furto do veículo, o que impõe o afastamento da qualificadora.

No que tange a causa de aumento do repouso noturno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos de mérito nos Recursos Especiais n.º 1.888.756/SP, n.º 1.890.981/SP e n.º 1.891.007/RJ, publicados em 27/6/2022, do Ministro Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, firmou recentemente a seguinte tese jurídica, de acordo com a ementa abaixo elencada:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE.

HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido”.

In casu, os acusados cometeram os delitos de furto qualificado, por volta das 20h00min e 23h40min. Desse modo, diante da tese jurídica fixada, considero, na primeira fase do procedimento dosimétrico, a causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável para ambos os delitos (artigo 59 do Código Penal).

Outrossim, restou evidenciado nos autos que, em duas oportunidades, os réus subtraíram objetos das vítimas, sendo que, no dia 22 de julho 2022, por volta das 20h00min, furtaram o veículo de Reinaldo e no dia 22 de julho 2022, por volta das 23h40min, furtaram a bateria automotiva do veículo da vítima Lady.

Embora praticados por meio de ações autônomas, os delitos de furto qualificado foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, restando configurada a continuidade delitiva.

Neste ponto, levando em conta o número de delitos praticados (dois furtos distintos), entendo que deva ser aplicada o aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva.

Consoante é o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (HC 490.707/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 01/03/2019).

Os crimes se consumaram. Sabidamente no crime de furto se adota a teoria do amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da res furtiva, sendo absolutamente dispensável a posse mansa e pacífica. No caso em apreço, os réus foram abordados em local diverso dos fatos, em poder dos bens subtraídos das vítimas, por policiais que sequer presenciaram as práticas delitivas, mas apenas tomaram conhecimento dos crimes após a sua consumação, o que torna inquestionável a consumação delitiva.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 934), de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, tratou da consumação do crime de furto firmando a seguinte tese:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. O Plenário do STF (RE 102.490-SP, DJ 16/8/1991), superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito

de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.346.113-SP, Quinta Turma, DJe 30/4/2014; HC 220.084-MT, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; e AgRg no AREsp 493.567-SP, Sexta Turma, DJe 10/9/2014. Precedentes citados do STF: HC 114.329-RS, Primeira Turma, DJe 18/10/2013; e HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe 10/5/2012." (REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada as culpabilidades, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seus comportamentos, é de rigor a condenação dos acusados Marcos e Diego, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

I -) Réu DIEGO NASCIMENTO FERREIRA:

Na primeira fase da pena, verifico que os acusados incidiram em duas qualificadoras para cada um dos crimes, o que já justifica o aumento da pena-base, pois de acordo com entendimento já consolidado, apenas uma qualifica o crime, devendo as demais servir como circunstância judicial desfavorável. Ademais, também deve ser considerada nessa fase a circunstância relativa ao cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno, pelas razões já expostas na fundamentação, haja vista que nenhuma circunstância pode ficar à margem da análise do Juízo. Além do mais, Diego apresenta péssima conduta social. Isto porque ele cometeu o crime durante o cumprimento de pena anteriormente aplicada em razão da prática de um furto majorado (processo de execução da pena n.º 0006610-26.2021.8.26.0041 do DEECRIM 1ª RAJ - fls. 228/229), o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Assim, acresço as penas de 1/3 (um terço), fixando as penas-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada delito de furto, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal. Na segunda etapa, presente a atenuantes da confissão. Presente, por outro lado, a

agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenações definitivas, transitadas em julgado, em datas anteriores aos fatos ora apurados, pelos delitos de furto qualificado (processo n.º 1500623-39.2020.8.26.0535, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0006607-71.2021.8.26.0041, do DEECRIM 1ª RAJ; processo n.º 1502116-85.2019.8.26.0535, da 3ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0018733-26.2020.8.26.0224, do DEECRIM 1ª RAJ e processo n.º 1502577-57.2019.8.26.0535, da 3ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0010316-84.2020.8.26.0224, do DEECRIM 1ª RAJ, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 228/232 e F.A. de fls. 194/199 e fls. 219/224), sendo, portanto reincidente específico. Assim, enquanto uma das condenações servem para compensar com a atenuante, as demais justificam o aumento das penas, razão pela qual acresço as penas de mais 1/6 (um sexto), fixando-as em 3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa para cada delito.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa para cada delito.

Considerando que os delitos de furto foram praticados em continuidade delitiva, tomo a pena privativa de liberdade de qualquer um deles, eis que idênticas (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), e acresço de 1/6 (um sexto), pelas razões acima expostas, totalizando a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão.

As penas de multa, a despeito da continuidade delitiva, deverão ser somadas, nos termos do artigo 72 do CP, totalizando 30 (trinta) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do benefício do sursis, diante do fato do réu ser reincidente específico.

II -) Réu MARCOS ROBERTO DA SILVA:

Na primeira fase da pena, verifico que o acusado incidiu em duas qualificadoras em cada um dos delitos de furto, o que já justifica o aumento da pena-base, pois de acordo com entendimento já consolidado, apenas uma qualifica o crime, devendo as demais servir como circunstância judicial desfavorável. Ademais, também deve ser considerada nessa fase a circunstância relativa ao cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno, pelas razões já expostas na fundamentação, haja vista que nenhuma circunstância pode ficar à margem da análise do Juízo. Outrossim, observo que o réu ostenta maus antecedentes, eis que possui condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, não apta a gerar reincidência (processo n.º 0061323-04.2009.8.26.0224, da 6ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos e processo n.º 0072957-07.2003.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, cuja pena foi julgada extinta em 27/06/2014, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 233/248 e F.A. de fls. 200/207 e fls. 208/2018 - 1ª e 2ª execução). Além do mais, Marcos apresenta péssima conduta social. Isto porque ele cometeu o crime durante o benefício de livramento condicional (processo de execução da pena n.º 0000094-58.2019.8.26.0041 da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos - fls. 233/234), o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o livramento condicional. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Assim, acresço as penas de 1/3 (um terço), fixando as penas-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada delito de furto, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda etapa, presente a atenuantes da confissão. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenações definitivas, transitadas em julgado, em datas anterior aos fatos ora apurados, pelos delitos de furto qualificado e roubo (processo n.º 0001078-49.2018.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0019507-57.2019.8.26.0041 da Vara das Execuções Criminais de Guarulhos e processo n.º 0001352-13.2018.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0000094-58.2019.8.26.0041, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 233/248 e F.A. de fls. 200/207 e fls. 208/2018), sendo, portanto reincidente específico. Assim, enquanto uma das condenações servem para compensar com a atenuante, as demais justificam o aumento das penas, razão pela qual acresço as penas de mais 1/6 (um sexto), fixando-as em 3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa para cada delito.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa para cada delito.

Considerando que os delitos de furto foram praticados em continuidade delitiva, tomo a pena privativa de liberdade de qualquer um deles, eis que idênticas (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), e acresço de 1/6 (um sexto), pelas razões acima expostas, totalizando a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

As penas de multa, a despeito da continuidade delitiva, deverão ser somadas, nos termos do artigo 72 do CP, totalizando 30 (trinta) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do benefício do sursis, diante do fato do réu ser reincidente específico.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO para os acusados DIEGO e MARCOS, considerando as circunstâncias do crime, além do fato dos acusados serem reincidentes específicos e terem voltado a delinquir, praticando o presente crime, o que evidencia que fazem do crime um meio de vida, bem como que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito, demonstrando maior

periculosidade dos denunciados e reprovação de sua conduta, sendo inadequado regime menos rigoroso.

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou as prisões preventivas não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade dos réus subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Assim, considerando as condições subjetivas, o fato dos acusados serem reincidentes específicos, além de terem permanecidos presos durante todo o processo, faz submergir a necessidade de segregação de DIEGO e MARCOS para garantir a ordem pública, evitando a reiteração de práticas delitivas, bem como assegurar a futura aplicação da lei penal, motivo pelo qual não poderão recorrer em liberdade.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

I - CONDENAR DIEGO NASCIMENTO FERREIRA, qualificado nos autos por infração ao artigo 155, § 4º, I e IV e artigo 155, § 4º, II e IV , afastada a incidência da majorante do repouso noturno prevista no §1º do citado artigo, c/c artigo 61, inciso e artigo 71, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 3 (TRÊS) ANOS, 7 (SETE) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

II - CONDENAR MARCOS ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos por infração ao artigo 155, § 4º, I e IV e artigo 155, § 4º, II e IV , afastada a incidência da

majorante do repouso noturno prevista no §1º do citado artigo, c/c artigo 61, inciso e artigo 71, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 3 (TRÊS) ANOS, 7 (SETE) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Os réus DIEGO E MARCOS não poderão recorrer em liberdade. Recomendem-se os réus no local onde se encontram presos.

Condeno os réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Defiro aos acusados os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que os acusados têm condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

P.I.C.

Guarulhos, 08 de novembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA